

1500705-25.2021.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Éverton Willian Pona

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... instaurada para a apuração do delito de tráfico de entorpecentes.

Não há preliminares a serem apreciadas ou nulidades a serem declaradas. O mérito há de ser conhecido.

2.1 Sobre o delito de tráfico de entorpecentes

A materialidade da conduta imputada ao réu encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01-02), boletim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capão Bonito

Foro de Capão Bonito

2ª Vara

Rua Rafael Machado, 50, Capão Bonito-SP - cep 18304-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500705-25.2021.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500705-25.2021.8.26.0571

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2132827/2021 - DEL.POL.CAPÃO

BONITO, 17940024 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 862/21/414 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 2132827 - DEL.POL.CAPÃO BONITO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS HENRIQUE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Éverton Willian Pona

Vistos.

1 RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública, sob o rito ordinário, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de MATHEUS HENRIQUE DA SILVA, já devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Segundo consta na denúncia (fls. 94-96), no dia 15 de maio de 2021, de madrugada, na Rua João Rui Dias, nº 74, Jardim da Amizade, nesta cidade e comarca, MATHEUS, tinha em depósito e guardava drogas, consistentes em uma porção a granel de

cocaína, com massa bruta de 17,5 gramas, e outras quatro porções da mesma droga, pesando 04 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o Ministério Público, em razão do adiantado da hora, policiais militares resolveram abordar a pessoa de Murilo Hideike, que era conhecido usuário de drogas. Nada de ilícito foi encontrado, e indagado por que estava no local, Murilo disse que havia ido buscar uma blusa na casa MATHEUS. Houve que, logo depois, o denunciado saiu de sua casa e foi igualmente abordado, e mais uma vez nada de ilegal se achou. Contudo, também questionado, MATHEUS disse que Murilo fora buscar uma bicicleta, e, diante da contradição de versões, terminou por admitir que estava vendendo drogas e franqueou a entrada dos policiais em sua casa.

No imóvel foram encontradas, em cima de uma estante indicada por MATHEUS, às porções de cocaína acima descritas e 120 microtubos vazios, além de uma balança de precisão, sacos para armazenar picolé, uma máquina para passar cartão e a quantia de R\$ 307,00.

Reperguntado, Murilo afirmou que havia comprado entorpecentes de MATHEUS em outras oportunidades (fls. 15).

Ante as circunstâncias da apreensão, a natureza e forma como as drogas estavam embaladas e os petrechos apreendidos, resta nítido, para o Ministério público, que a finalidade do agente era a promoção do narcotráfico.

Acompanharam os autos deste processo o recebimento da denúncia às fls. 99-102, seguindo-se a regular citação do réu (fl. 114), com posterior apresentação de resposta à acusação (fls. 115-116).

Realizou-se audiência de instrução na qual foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu. Nada foi requerido na fase no art. 402, do Código de Processo Penal.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa requereu...

É o relatório. Passo à fundamentação e decisão.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação penal instaurada para a apuração do delito de tráfico de entorpecentes.

Não há preliminares a serem apreciadas ou nulidades a serem declaradas. O mérito há de ser conhecido.

2.1 Sobre o delito de tráfico de entorpecentes

A materialidade da conduta imputada ao réu encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01-02), boletim de ocorrência (fls. 03-05), auto de exibição e apreensão (fls. 06-07), auto de constatação preliminar (fls. 09-10), laudo de exame químico-toxicológico definitivo positivo para cocaína (fls. 125-128), relatório investigativo do aparelho de telefone celular (fls. 130-143) e pela prova oral colhida em juízo.

Em relação à autoria, de se considerar que o réu, foi preso em flagrante delito, e na fase policial, disse que: estava dormindo; escutou o cachorro latindo e ao se levantar, se deparou com policiais militares que estavam dentro do quintal de sua casa; foi abordado no quintal; os policiais o revistaram e perguntaram se havia drogas dentro da casa; os policiais não pediram autorização para entrar em sua minha casa; relatou aos policiais que mantinha dentro de casa uma balança, pinos para acondicionar cocaína e um pouco de cocaína; havia encontrado no meio da pista as drogas e os pinos embolados em um saco preto; o dinheiro apreendido pelos policiais é de sua namorada que trabalha como babá; não vende drogas; estava vendendo cada pino de cocaína por R\$10,00. (fls. 16-17).

Interrogado em juízo disse que: achou as drogas na pista próximo à sua residência e levou para casa; não estava vendendo; achou tudo numa sacola; ia tentar distribuir a droga pois estava passando por apuro financeiro.

A testemunha, Samuel Fogaça de Almeida, policial militar, ouvido em solo policial,

disse que: estava de serviço com o colega policial Matos; por volta de 01:08 horas, durante patrulhamento pela Rua João Rui Dias, 74, Jardim da Amizade; avistaram defronte ao numeral mencionado a pessoa de Murilo Antônio Hideike Saito, conhecido por ser usuário de drogas, sendo o mesmo revistado, porém nada de ilegal apreenderam na sua posse; indagado sobre sua presença naquele local, disse que tinha ido buscar uma blusa na casa MATHEUS; durante a abordagem de Murilo saiu da residência número 74 a pessoa de MATHEUS, que também foi submetido à abordagem e a revista pessoal, nada de ilegal sendo encontrado; na indagação de ambos percebeu-se contradições nas alegações, ou seja, Murilo falou que tinha ido buscar uma blusa, enquanto que MATHEUS falou que ele tinha ido buscar uma bicicleta; durante essas contradições, MATHEUS confessou que estava comercializando drogas na residência dele e que dentro da casa tinha droga, cocaína, permitindo a entrada na residência conforme assinatura em sua versão dos fatos no BOPM); apontou em cima de uma estante onde estava o entorpecente; em cima do móvel foi encontrada uma quantidade de substância análoga à cocaína, ou seja, 4 pinos contendo pó branco, que pesou 4 gramas e mais uma quantidade a granel, que pesou 17, 5 gramas, e 120 microtubos vazios; encontrado também a quantia de R\$ 307,00 reais em dinheiro, uma balança de precisão, uma máquina de passar cartão de crédito e um aparelho celular, tudo apresentado ao plantão para a devida apreensão; foi dada voz de prisão a MATHEUS e apresentado ao Plantão policial. (fl. 08).

Em juízo relatou que: estavam em patrulhamento e abordaram Murilo em frente a casa e MATHEUS; quando o réu saiu da residência foi revistado e nada de ilícito foi encontrado; abordados separadamente, Murilo disse que tinha ido buscar uma blusa; MATHEUS disse que Murilo tinha ido buscar uma bicicleta; diante da versão contraditória, após questionamento, MATHEUS confessou que estava traficando entorpecentes, os quais foram encontrados no interior da residência; não conhecia MATHEUS; estavam realizando uma operação no dia dos fatos.

A testemunha, Paulo Rafael de Matos, policial militar, ouvido em solo policial, disse que: estava de serviço com o colega policial Almeida; por volta de 01:08 horas, durante patrulhamento pela Rua João Rui Dias, 74, Jardim da Amizade; avistaram defronte ao numeral mencionado a pessoa de Murilo Antônio Hideike Saito, conhecido por ser usuário de drogas, sendo o mesmo revistado, porém nada de ilegal apreenderam na sua posse; indagado sobre sua presença naquele local, disse que tinha ido buscar uma blusa na casa MATHEUS; durante a abordagem de Murilo saiu da residência número 74 a pessoa de MATHEUS, que também foi submetido à abordagem e a revista pessoal, nada de ilegal sendo encontrado; na indagação de ambos percebeu-se contradições nas alegações, ou seja, Murilo falou que tinha ido buscar uma blusa, enquanto que MATHEUS falou que ele tinha ido buscar uma bicicleta; durante essas contradições, MATHEUS confessou que estava comercializando drogas na residência dele e que dentro da casa tinha droga, cocaína, permitindo a entrada na residência conforme assinatura em sua versão dos fatos no BOPM); apontou em cima de uma estante onde estava o entorpecente; em cima do móvel foi encontrada uma quantidade de substância análoga à cocaína, ou seja, 4 pinos contendo pó branco, que pesou 4 gramas e mais uma quantidade a granel, que pesou 17, 5 gramas, e 120 microtubos vazios; encontrado também a quantia de R\$ 307,00 reais em dinheiro, uma balança de precisão, uma máquina de passar cartão de crédito e um aparelho celular, tudo apresentado ao plantão para a devida apreensão; foi dada voz de prisão a MATHEUS e apresentado ao Plantão policial. (fl. 11).

Em juízo relatou que: estavam em patrulhamento quando avistaram Murilo em frente a residência de MATHEUS; Murilo é conhecido dos meios policiais e mora bem distante do local, na Vila Aparecida; Murilo disse que ia buscar uma blusa; MATHEUS saiu da residência e, abordado, afirmou que Murilo ia buscar uma bicicleta; diante da contradição, questionaram MATHEUS e ele confessou que estava traficando; na residência do réu encontraram cocaína, balança de precisão, dinheiro trocado; conduziram ambos à Delegacia; nada de ilícito foi encontrado com Murilo; a abordaram Murilo e nada de ilícito foi encontrado, porém ele é bastante conhecido nos meios policiais como usuário/traficante, além de seu envolvimento com outros possíveis delitos que estão sendo paur.

A testemunha, Murilo Antônio Hideike Saito, policial militar, ouvido em solo

policial, disse que: usa somente o entorpecente maconha; na data dos fatos, foi na casa de seu amigo MATHEUS para buscar uma blusa que tinha emprestado ao amigo; após pegar a blusa com o amigo, apareceu a viatura policial, sendo então o depoente abordado e revistado; nesse momento, MATHEUS saiu da casa para ver o que acontecia e foi revistado também; após MATHEUS ser revistado, ele entrou na casa com os policiais; os policiais saíram com as drogas encontradas na casa de MATHEUS; nesta oportunidade não comprou drogas de MATHEUS, mas confirma que já adquiriu entorpecente, maconha, de MATHEUS, e que o pedido foi por WhatsApp, sendo a droga entregue na rua; na casa de MATHEUS o depoente informa que nunca comprou. (fl. 15). Em juízo relatou que: fui até a residência para buscar uma blusa e uma bicicleta que ia fazer uma revisão e lavar; foi abordado pelos policiais; nunca comprou droga de MATHEUS mas já recebeu meio pino de cocaína e um cigarro de; No que tange ao depoimento de policiais, ressalta-se não existir dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprir em seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal”. (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

No caso sob análise, a atuação dos agentes policiais revestiu-se de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. Os depoimentos dos policiais foram seguros, coesos e harmônicos entre si, dotados de credibilidade e com força probatória. Nada existe de concreto nos autos a indicar que os policiais ouvidos em juízo estivessem tentando incriminar falsamente o réu, atribuindo-lhe o falso cometimento de um delito.

Do contexto probatório dos autos extrai-se que ambos os policiais, Alexandre e Paulo, prestaram declarações em juízo no mesmo sentido o que haviam afirmando perante a Autoridade Policial. Com efeito, ao observarem Murilo, pessoa muito conhecida nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de entorpecentes, os policiais resolveram abordá-lo. O motivo apresentado para estar no local (supostamente para buscar uma blusa) foi incompatível com o que relatou MATHEUS (que Murilo lá estava para buscar uma bicicleta).

Após nova indagação, MATHEUS confessou que havia drogas em sua residência e, ao adentrarem no imóvel devidamente autorizados, os policiais encontraram 4 eppendorfs contendo cocaína, além de outro invólucro com outra porção da mesma droga. Além disso, também foi apreendida uma balança de precisão, uma máquina de cartão de crédito, 120 eppendorfs vazios, 30 saquinhos diversos de “sacolê”, comumente utilizados para a embalagem de drogas, 1 celular e R\$ 307,00 em espécie, em notas trocadas.

O réu alegou que encontrou todos os objetos na rua e levou para sua residência.

Negou que estivesse de fato traficando, mas que intentava distribuir a droga.

Murilo alterou seu depoimento em juízo para ajustá-lo ao que havia dito MATHEUS e fazer desaparecer a contradição apontada pelos policiais. Veja-se que na Delegacia ele mencionou ter ido buscar a blusa – como os policiais relataram que Murilo

afirmou no momento da abordagem. Em juízo, já relatou ter ido buscar a blusa e a bicicleta (acrescentando o motivo dado por MATHEUS no momento da abordagem). Além disso, na Delegacia Murilo afirmou que o réu saiu para ver o que estava acontecendo e então foi abordado; perante este juízo, que os policiais entraram na residência e apenas após esse fato MATHEUS saiu.

Por fim, em juízo, Murilo declarou nunca ter comprado drogas de MATHEUS, mas apenas ter recebido meio pino de cocaína. Na Delegacia, nada revelou sobre essa circunstância, admitindo que comprara maconha, negociada pelo whatsapp.

Por todas essas contradições e por se tratar de pessoa conhecida nos meios policiais pelo seu envolvimento com o tráfico, as suas declarações devem ser ponderadas com cuidado e, quando confrontadas com o quanto afirmado pelas testemunhas policiais, não se sustentam.

Há mais a se considerar. Às fls. 130-143 consta o relatório circunstanciado do celular apreendido do qual se extrai que Murilo já havia mantido contato com MATHEUS e há evidências das negociações que, ao que tudo indica, eram recorrentes. MATHEUS também negocia entorpecentes com outras pessoas e, como destacou o Ministério Público, com seu possível fornecedor (indicado como Lava Rápido). Um interlocutor denominado "Vein" diz para o réu cuidar bem do "pó", em clara referência ao entorpecente apreendido na residência.

Não há dúvidas de que a versão de MATHEUS não se sustenta quando analisado o conjunto probatório. Ele, de fato, estava traficando entorpecentes e vinha fazendo, ao que se pode concluir, dessa atividade seu meio de vida.

Portanto, não há dúvida sobre a ocorrência do fato delituoso e de sua autoria.

O réu, de forma consciente e espontânea, mantinha a guarda e tinha em depósito, para fins de tráfico, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que se amolda formalmente à previsão abstrata do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Com isso, resta preenchida a tipicidade formal.

Caracterizada, pois, a tipicidade formal objetiva, imperioso destacar a presença, também, da tipicidade material, ante a efetiva violação do bem jurídico protegido pela norma, bem como, dos elementos subjetivos do tipo. O réu agiu com dolo, nas modalidades cognitiva e volitiva, pois evidente tratar-se de conduta deliberada. O fato é típico, portanto.

Outrossim, não se verificam presentes quaisquer das causas excludentes da antijuridicidade da conduta, previstas no art. 23, do Código Penal. O fato descrito é, assim, típico e ilícito.

Além disso, o réu possui plena capacidade penal e pode ser responsabilizado por seus atos. É penalmente imputável e possui condições de compreender a ilicitude de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Segundo se observa nos autos, possuía conhecimento suficiente, à época dos fatos, para perceber a ilegalidade de sua ação e agir, se assim quisesse de outra forma. Optou pela conduta ilícita quando dele era exigível comportamento diverso. Por tais razões, a sua conduta é culpável.

Desse modo, por se tratar de fato típico, antijurídico e culpável, ausentes quaisquer causas de exclusão da ilicitude, culpabilidade ou de extinção da punibilidade, mostra-se imperiosa a condenação do réu MATHEUS HENRIQUE DA SILVA nas penas do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

2.2 Individualização da pena

Fixadas tais premissas, passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 59, do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas. Adota-se, para a dosimetria da pena, o sistema trifásico previsto no art. 68, do Código Penal.

2.2.1 Dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria a culpabilidade mostra-se normal e inerente ao delito; não constam antecedentes; não há informações sobre a conduta social ou sobre a personalidade do réu; os motivos são inerentes ao delito, assim como as

circunstâncias e as consequências. Não se observa, por fim, qualquer contribuição do comportamento da vítima.

No caso de tráfico de drogas, deverá ser considerado com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42, da Lei de Drogas). Quanto à natureza, observa-se ter sido apreendida cocaína. Não há maior reprovabilidade quanto a essa circunstância. Em relação à quantidade, foram apreendidos uma porção a granel de cocaína, com massa bruta de 17,5 gramas, e outras quatro porções da mesma droga, pesando 04 gramas. O montante já se mostra suficiente para ensejar maior reprovação, de modo que a circunstância deve ser considerada negativa.

Em relação ao quantum do aumento nesta fase da dosimetria prevalece na jurisprudência, em razão da ausência de previsão específica na legislação, competir ao magistrado sopesar as especificidades do caso concreto e atribuir o devido valor a cada uma das circunstâncias judiciais. Confira-se:

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O CP não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 107.860, rel. min. Rosa Weber, 1ª T, DJE de 25-9-2012.)

O STF submete a legalidade da pena ao fundamentado exame judicial das circunstâncias do delito. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante. O art. 59 do CP confere ao juízo sentenciante o poder-dever de estabelecer uma reprimenda apta à prevenção e simultaneamente à reprovação do delito, sempre atento o magistrado à concretude da causa. Sucede que, em situações como a retratada nos autos, o juiz sentenciante há de considerar parâmetros que são próprios da legislação de drogas. Parâmetros constantes do art. 42 da Lei 11.343/2006. Pelo que o caso é de calibração das balizas do art. 59 do CP com as circunstâncias listadas na pertinente legislação extravagante. No caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e da quantidade de droga apreendida. O que não discrepa da jurisprudência do STF (RHC 108.878, rel. min. Ayres Britto, 2ª T, DJE de 21-11-2011).

Em reflexão sobre a forma de atribuição do quantum atinente a cada circunstância judicial, este magistrado entende, em aperfeiçoamento a posicionamentos anteriores, que a majoração da pena nesta fase da dosimetria em um percentual fixo (1/6 ou 1/8) sobre a pena mínima abstrata prevista na legislação ignora por completo a previsão legislativa acerca do limite máximo da reprimenda estabelecido, tratando de forma igual crimes com gravidade distintas, o que, em última análise, viola o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).

Isso porque a individualização da pena apresenta-se em três momentos distintos: o legislativo (cominação abstrata da pena), com a fixação dos limites mínimo e máximo da pena; o judicial, com o estabelecimento da pena in concreto; e no momento da execução da pena, quando tem influência o comportamento individual do apenado para a concessão dos benefícios previstos na legislação.

A fase legislativa, de cominação abstrata da pena, representa a reprovabilidade do corpo social em relação à conduta tornada crime. Assim, no momento da aplicação, ignorar que crimes com a mesma pena base podem ostentar penas máximas distintas corresponde a sobrepor-se à reprovação da conduta externada pela sociedade por intermédio dos legisladores.

Desse modo, por serem 10 as circunstâncias constantes no caput do art. 59, do CP, somadas, entende-se que o quantum a ser atribuído a cada uma delas é de, no mínimo, de 1/10 entre a diferença da pena mínima e máxima fixada para o delito. Contudo, forte na jurisprudência, as especificidades do caso autorizam ao magistrado a atribuir maior relevância a uma ou outra circunstância, desde que devidamente fundamentado.

Considerando que no presente caso reconheceram-se duas circunstâncias como

negativas (a quantidade da substância), acresço ao piso 1/10 da diferença entre o mínimo e o máximo abstratamente cominado ao delito e fixo a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. Está presente uma atenuante, pois o agente era menor de 21 anos na data do fato (artigo 65, inciso I, primeira parte, do Código Penal), razão pela qual atenuo a pena 1/6, tornando a pena provisória em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, apesar da primariedade, observa-se que o réu estava fazendo do tráfico sua atividade habitual. A perícia realiza em seu celular não deixa dúvida de seu envolvimento sistemático com o tráfico de entorpecente, inclusive com movimentação de grande quantidade de drogas. Por isso, deixo de aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Torno definitiva a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2.2.2 Regime inicial de cumprimento da pena

Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário esclarecer que o réu foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, o qual é equiparado ao hediondo e, por força do art. 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da determinação por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES, em 27/06/2012. Assim sendo, não há vedação à fixação de regime inicial diverso do fechado, mesmo a condenados por tráfico de drogas, consoante o entendimento do STF, por força da necessária individualização da pena, que implica na necessidade de se observarem as circunstâncias do caso concreto e de cada condenado.

Nos termos do art. 59, III, do Código Penal, considerando o requisito objetivo (a quantidade de pena fixada em 5 anos de reclusão), o fato de o réu não ser reincidente e tendo em vista as circunstâncias judiciais (art. 33, §3º, do CP), a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente semi-aberto.

2.2.3 Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis

No caso o réu foi condenado a pena superior a 4 anos, não satisfazendo o requisito objetivo para a substituição ou para a suspensão condicional da pena.

2.2.4 Fixação do valor do dia-multa

Em atendimento ao disposto no art. 49, §1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do réu.

2.2.5 Detração

A aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (detração a ser realizada pelo juiz na sentença) carece de uma melhor regulamentação, visto ser dispositivo assemelhado aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais.

Nesse sentido, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação Criminal – Recepção. Sentença condenatória. Recurso Defensivo pleiteando o reconhecimento da detração para fixar o regime aberto para cumprimento da pena. Materialidade e autoria provadas - Réu surpreendido na condução de veículo produto de furto - Depoimento do policial que merece credibilidade, sendo coeso e harmônico em relação ao conjunto probatório - Confissão judicial do réu que corrobora as demais provas produzidas em juízo - Manutenção da condenação de rigor - Dosimetria das penas - Pena-base fixada no mínimo legal - Manutenção da compensação da circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência, por ausência de reclamo Ministerial - Entendimento predominante no sentido de que a reincidência

prepondera sobre a confissão, nos termos do art. 67, do Código Penal – Vedação da reforma tío in pejus – Penas inalteradas – Regime inicial semiaberto que se mantém em razão da reincidência registrada – Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Detração da pena – questão que deve ser melhor analisada em sede de execução criminal – Recurso improvido. (TJSP; Apelação 0068936-68.2016.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017)

Do teor do acórdão extrai-se:

No tocante a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendendo não ser possível sua aplicação, eis que inviável a análise de requisitos subjetivos [...].

No mesmo sentido, recente julgado da 8ª Câmara Criminal do Tribunal Bandeirante, na Apelação nº 016797-87.2012.8.26.048, Relator: Lauro Mens de Melo, donde se extrai que, "inicialmente, inviável entender-se que o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal pode ser considerado como alteração de regime inicial a partir de pena cumprida, funcionando como progressão indireta". Além disso, "trazer para o processo de conhecimento numerosos dados acerca da execução tumultuária o processo, tornaria a prestação jurisdicional confusa e mais demorada, o que certamente vai de encontro aos interesses da defesa".

Com efeito, a progressão do regime por este juízo, em decorrência de custódia cautelar, requer o acesso a dados pessoais do réu, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui os requisitos objetivo e subjetivo. Ademais, a detração somente pode ser adequadamente apreciada pelo juízo da execução, que pode analisar todas as condenações do réu e evitar que o mesmo período de custódia cautelar seja utilizado para abatimento das penas em mais de um processo.

Tal análise deve ser feita no âmbito da execução penal, pelo que deixo de realizar a detração.

3 DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu MATHEUS HENRIQUE DA SILVA pela prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semi-aberto e ao pagamento de 500 dias-multa.

FIXO valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos CONDENO o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP) e, com base no art. 15, III, da Constituição Federal, enquanto durarem os efeitos da condenação, DETERMINO a suspensão de seus direitos políticos.

4 DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Prisão preventiva

Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, DEIXO DE DECRETAR a prisão preventiva, pois o réu foi condenado a pena a ser cumprida em regime semi-aberto e a custódia cautelar seria mais rigorosa do que o próprio cumprimento da reprimenda.

4.2 Decretação de perdimento dos valores apreendidos

Decreto o perdimento dos bens apreendidos às fls. 06-07 por serem produto de atividade criminosa.

4.3 Determinações finais e comunicações

Comunique-se a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ) e, com o trânsito em julgado:

a) Intime-se o réu para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, do CP e art. 480, das NSCGJ), bem como das custas judiciais no prazo de 60 dias (art. 480, §1º, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento da multa no prazo assinalado, extraia-se certidão da sentença nos termos do art. 480-A, das NSCGJ;

b) Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ);

c) Expeça-se de guia de recolhimento definitiva ou oficie-se aditando a guia provisória (art. 472, das NSCGJ) e mandado de prisão;

d) Determino a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas e ainda não destruídas (art. 72, da Lei nº. 11.343/2006);

e) Comunique-se a SENAD, para o fim previsto no art. 63, §§ 2º e 4º, da Lei nº. 11.343/2006, remetendo relação dos bens e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, os locais em que se encontram e a entidade ou órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente;

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Capão Bonito, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA